

1500613-30.2022.8.26.0630
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Estelionato
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/10/2022
... 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500613-30.2022.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500613-30.2022.8.26.0630
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164473/2022 - 03º D.P. AMERICANA, 25608402 - 03º D.P. AMERICANA, 2164473 - 03º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HENI DE OLIVEIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.
HENI DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 171, "caput", por duas vezes, e no art. 171, "caput", c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, nas datas e locais descritos na denúncia, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de J.V.N. e V.M.S., no montante de R\$ 3.900,00, a quem induziu e manteve em erro mediante emprego de artifício/fraude. Consta, ainda, que tentou obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo de L.H.S.A., no montante de R\$ 1.950,00, a quem induziu e manteve em erro mediante emprego de artifício/fraude, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra, ainda, a exordial que:

Segundo foi apurado, as vítimas J.V.N. e V.M.S. souberam através de uma rede social que o ingresso para o “Camarote Brahma” da Festa do Peão de Americana, para o dia 18/06/2022, poderia ser adquirido por R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); interessados, mantiveram contato com “Matheus Nascimento” pelo telefone (24) 99971-1850, culminando por agendar um encontro no dia 16 de junho deste ano no “Shopping Welcome Center”, às 13h00.

O denunciado, apresentando-se como amigo de “Matheus Nascimento”, iniciou as tratativas para a venda de 06 (seis) ingressos para “Camarote Brahma”, exibindo-os, bradando que não poderia comparecer porque estava escalado para trabalhar na aludida data, por isso a necessidade de vendê-los, chegando a lacrimejar.

Efetivado o negócio, e induzidos em erro por supor que nada de irregular afluía, vale dizer, que eram falsos, as vítimas realizaram o pagamento à vista por meio de transferência via PIX (comprovante a ser juntado). As vítimas notificaram para o ofendido L.H. a compra dos ingressos, que também se mostrou interessado. Realizaram novo contato e combinaram se encontrar no dia seguinte, 17 de junho de 2022, no horário e no aludido “shopping”, sendo certo que L.H. pretendia adquirir mais três ingressos. O denunciado lá compareceu e encontrou as três vítimas, dizendo que se chamava “Roberto”, causando estranheza para as vítimas Vitor e João; imediatamente as vítimas manusearam os ingressos e constataram que todos continham o mesmo código de barras, sendo falsos.

Disseram que precisavam se afastar e deixaram o denunciado conversando com L.H. Saíram do “shopping” e avistaram uma viatura da Polícia Militar; conversando com os policiais, relataram o que estava acontecendo, momento em que ingressaram no estabelecimento e abordaram o denunciado efetivando a negociação com aquela vítima, sendo que tinha dois ingressos e um estava na mão da vítima.

Os policiais militares visualizaram todos os ingressos e constataram que tinham o mesmo código de barras (63.3184.4914.8905830688885867), vale dizer, eram falsos. Tal fato foi suficiente para desencadear a prisão em flagrante, situação tal que impediu a consumação da venda dos ingressos falsos para o ofendido L.H.

O laudo pericial juntado às fls. 134/141 atesta que todos os ingressos são falsos pois não exibiam as características e os elementos de segurança documental dos ingressos autênticos.

Assim agindo, o denunciado, obteve, para proveito próprio, de forma fraudulenta, vantagem ilícita no montante de R\$ 3.900,00 em prejuízo das duas primeiras vítimas, e tentou obter mais R\$ 1.950,00 ludibriando a terceira vítima.

As vítimas representaram às fls. 05, 06 e 07.

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2022 (fls. 159/160).

O réu foi citado (fls. 189), apresentando defesa (fls. 209/211).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 219/220).

Em seus memoriais (fls. 224/228), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se (fls. 231/238), a Doutora Defensora do acusado alegou a irregularidade do flagrante e requereu a absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena mínima e regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Estelionato é o fato de o sujeito obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelos autos de fls. 01/02, 10/14, 17/18 e 19/26, documentos de 197/198 (depósito/transferência), e laudo de fls. 134/141 (comprovando a falsidade material).

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

Preliminarmente, nada a prover acerca do alegado flagrante preparado. As informações das vítimas são claras ao confirmar que apenas suspeitaram do embuste quando da segunda compra de ingressos e, em razão disso, obtiveram auxílio de policiais, os quais se encontravam em local próximo, para verificar a ocorrência da ilicitude.

Habeas Corpus. Estelionato e associação criminosa. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Condições subjetivas favoráveis da paciente. Decisão genérica. Liminar indeferida. 1. (...). 2. Inobservância da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal não verificada. Intervenção policial que foi precedida de informações prestadas pelos funcionários da agência bancária que suspeitaram do comportamento dos acusados em razão da prática de estelionato no dia anterior. Hipótese que não indica o chamado flagrante preparado ou provocado. (...). (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2163684-04.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

ESTELIONATO TENTADO Golpe do bilhete premiado Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e por entender não ter configurado o crime de estelionato, ante a ausência de prejuízo à vítima e evidente hipótese de crime impossível, em razão do flagrante preparado Vítima que desconfiada, comentou com familiares que denunciaram a ação à polícia Autoria e materialidade comprovadas Meio empregado pelos agentes perfeitamente capaz de produzir o resultado esperado, não se consumando o crime por circunstância alheia à suas vontades (...). (TJSP; Apelação Criminal 9000005-06.2006.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2012; Data de Registro: 01/02/2012)

Não há, ainda, falar-se em atipicidade da conduta, porquanto o réu usou de meio fraudulento para obter vantagem ilícita, qual seja, a venda de bilhetes falsos.

Além disso, nem sequer procurou as vítimas para efetuar o ressarcimento do valor depositado.

Não há dúvida que tal conduta tipifica o delito de estelionato. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

ESTELIONATO – materialidade – boletim de ocorrência, documentos bancários e prova oral confirmando que o réu obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima Leonardo Moraes induzindo em erro a vítima mediante fraude consistente em realizar depósitos bancários com envelopes vazios. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0002884-25.2015.8.26.0568; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 02/08/2017)

Estelionato. Autoria e materialidade incontestes. Vantagem ilícita. Acusada que cria anúncio fictício de venda de uma motocicleta em rede social e, captado o interesse das vítimas, com elas negocia e exige valor inicial ao argumento de que precisaria retirar o veículo da oficina ou providenciar documentos para então entregá-lo ao comprador. Relatos das vítimas seguros e coerentes, respaldados pela ampla confissão da acusada. Dolo comprovado. Prova oral hábil. Condenação de rigor. Penas bem dosadas. Impossibilidade de reconhecimento de crime único, considerando que houve duas ações autônomas que atingiram patrimônios distintos. Substituição que atende à finalidade da lei penal. Regime aberto, para o caso de descumprimento, adequado. Recurso do Ministério Público postulando a revisão do valor da prestação pecuniária, cujo mínimo é de um salário mínimo, e sua destinação às vítimas. Apelo ministerial provido para esse fim. Apelo defensivo improvido, afastada a matéria preliminar. (TJSP; Apelação Criminal 1500368-80.2019.8.26.0482; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2022; Data de Registro: 01/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR EX OFFICIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. NO CASO, CONSTATA-SE A PLENA OBSERVÂNCIA AOS DISPOSITIVOS ADICIONADOS AO CÓDIGO PENAL E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA NOVEL LEGISLAÇÃO, QUE ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR EXIGUIDADE DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO OBTVEU PARA SI VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA VÍTIMA, QUE FOI MANTIDA EM ERRO MEDIANTE FRAUDE, CONSISTENTE REALIZAR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ENVELOPES VAZIOS E CONTENDO CHEQUES SEM FUNDOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM RELEVANTE EFICÁCIA PROBATÓRIO. ASSERTIVAS CORROBORADAS PELA INQUIRIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E TESES DEFENSIVAS FRÁGEIS E ISOLADAS. CONDENÇÃO IMPOSITIVA. ROGO DE NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PROPORCIONAL E DISCRICIONÁRIA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. FUNDAMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DA GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA PRATICADA PELO IMPUTADO. PRECEDENTES. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. o conjunto probatório é suficiente a demonstrar que o réu obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro mediante fraude, consistente em realizar depósitos bancários com envelopes vazios e contendo cheques sem fundos. II. Nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima é relevante e possui eficácia probatória bastante para embasar a condenação, mormente quando estiver em harmonia com os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III. Enquanto os elementos sustentadores da versão acusatória se revelaram suficientemente sólidos e harmônicos, as teses ventiladas pela defesa e a versão do réu se mostraram frágeis e isoladas, não conseguindo, portanto, infirmar a certeza condenatória. IV. O alibi, como meio de provar a inocência do acusado, deve extrair por completa a possibilidade de praticar a conduta que lhe é imputada, de forma que se torne impossível ter cometido aquele delito, entretanto, não fazendo prova satisfatória quanto ao alegado, não pode ser reconhecida a inocência com base em meras ilações. V. A fixação da reprimenda basilar deve ser mantida em sua integralidade, porquanto resultante de ampla e adequada avaliação, apta e

suficiente para justificar os acréscimos - observados os limites das penas mínima e máxima abstratamente cominadas - proporcionalmente aplicados. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000292-30.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 18.05.2020)

Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima, no sentido de que o réu efetuou a compra de um veículo automotor mediante pagamento efetuado com depósitos bancários em caixa eletrônico, utilizando-se de envelopes vazios. Condenação mantida. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Redução da pena-base. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0012950-71.2012.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)

ESTELIONATO - Agente que obtém vantagem indevida para si mediante emprego de meio fraudulento idôneo no momento em que preenche e assina cheques pertencentes a terceiro - Configuração - Ocorrência:14(a) - Configura o crime de estelionato a conduta do agente que obtém vantagem indevida para si mediante o emprego de meio fraudulento idôneo, no momento em que preenche e assina cheques pertencentes a terceiro, paga a mercadoria e causa prejuízo ao estabelecimento comercial-vítima, o qual não é ressarcido. (Apelação nº 1.271.569/4, Julgado em 13/11/2.001, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo (Presidente), RJTACRIM 57/60)

ESTELIONATO - Pagamento de mercadoria com cheque furtado - Evidência da intenção dolosa do agente - Ocorrência:37(a) - Ementa oficial: Estelionato - Ausência de dolo alegada - Inadmissibilidade - Pagamento de mercadorias com cheque furtado - Evidência da intenção dolosa do agente, em ludibriar as vítimas - Condenação mantida..(Apelação nº 1.019.767/9, Julgado em 23/09/1.997, 10ª Câmara, Relator: Teodomiro Méndez, RJTACRIM 36/198).

A testemunha/vítima Vitor, ouvida em Juízo, declarou que junto com João decidiram comprar ingressos do camarote da festa do peão, sendo que João entrou em contato com o réu, e marcaram para a compra. Narrou que fizeram a compra de seis ingressos, no valor de R\$ 3.900,00, e aconselharam o amigo Luís a adquirir também. Informou que os ingressos na festa encontravam em mais de R\$ 1.000,00, no lote atual. No dia seguinte, Luís marcou com o réu, e foram todos juntos para a aquisição, ocorre que quando pegaram os ingressos, nessa segunda aquisição, perceberam que os códigos de barra estavam iguais. Nesse momento, o depoente e João saíram da mesa, e encontram os policiais, solicitando ajuda. Narrou que os policiais confirmaram que os códigos de barra estavam iguais, e efetuaram a abordagem. Confirmou que os ingressos adquiridos previamente, pelo depoente e por João, também possuíam código de barras idêntico aos da tentativa de venda para Luís. Por fim, confirmou que a mesma pessoa fez ambas as vendas, reconhecendo o réu. E, não recuperou o valor pago.

A testemunha/vítima João, ouvida em Juízo, declarou que através do "Facebook" encontrou um rapaz, com nome de "Matheus Nascimento" que estaria vendendo ingressos da festa do peão, tendo entrado em contato pelo "WhatsApp", para a compra de seis ingressos, no valor de R\$ 650,00, cada um. Narrou que marcaram o encontro no shopping "WelcomeCenter", tendo adquirido os ingressos seus e de Vitor, e pago através de um "Pix" para a pessoa de Heni. Após, a aquisição, indicaram o réu para o amigo Luís, que também queria adquirir ingressos, e no dia seguinte o acompanharam, momento em que verificaram que os códigos de barra estavam todos iguais. Informou que o depoente e Vitor retiram-se da conversa e avistaram os policiais, solicitando auxílio. Confirmou que na segunda tratativa o réu se identificou como "Roberto" ou "Rogério". Por fim, reconheceu o réu como o autor de ambas as vendas. E, não recuperou o valor pago.

E, a testemunha/vítima Luís, ouvida em Juízo, declarou que no dia anterior as vítimas Vitor e Joao fizeram uma compra de ingressos com o réu, e como o depoente também queria ir no evento eles indicaram o réu para comprar. No dia dos fatos, os dois acompanharam o depoente para a aquisição dos ingressos, e enquanto estava na mesa com o réu, seus amigos verificaram os ingressos e saíram, sendo que quando retornaram estavam com a polícia. Durante as tratativas, o réu alegou que ganhou os ingressos, com alguns amigos, e como não poderiam ir, então queriam vender, razão do valor abaixo do normalmente cobrado. Narrou que foi informado, então, que os amigos perceberam que os códigos de barra dos ingressos eram iguais, razão pela qual chamaram a polícia. Confirmou que tinha intenção de adquirir dois ingressos, sendo que o valor oficial, de cada um, na festa estaria em torno de R\$ 1.000,00, e o réu estaria vendendo por R\$ 650,00. Declarou que os amigos perceberam, durante a segunda tentativa de venda, que os ingressos tinham códigos de barra igual, inclusive com os anteriormente vendidos. Por fim, reconheceu o réu como autor do delito.

Não há nos autos prova de que as vítimas conheciam o réu anteriormente ou que tivessem intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação. De acordo com a doutrina:

"...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime.

O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136).

A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade.

Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.

Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas.

Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil.

(...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' (JTACrim 51:423).

'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes' (RT, 484:320). No mesmo sentido: JTACrim, 60:314, 64:193, 73:79 e 22:354. (CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 150/151).

Sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

Apelação criminal. Estelionato. Autoria. Prova. Valor do depoimento da vítima. Em crimes patrimoniais ? notadamente no estelionato cometido com um falso relacionamento amoroso prometido pelo agente ? a palavra da vítima assume especial importância, notadamente quando sustentada ainda por provas efusivas do procedimento enganoso do acusado. (TJSP; Apelação Criminal 3000744-98.2013.8.26.0062; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bariri - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)

Estelionato – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade Nos crimes de estelionato, a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar a dinâmica da subtração. (TJSP; Apelação Criminal 0003741-21.2015.8.26.0132; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Os policiais militares, ouvidos, informaram que estavam em patrulhamento quando foram solicitados por dois jovens informando que um terceiro estaria comprando ingressos para a “Festa do Peão” e estavam desconfiando que o ingresso seria falso, tendo em vista que compraram ingressos na data anterior, e os códigos de barra seriam idênticos. Narraram que efetuaram a abordagem durante as tratativas de venda, e com o réu foram encontrados três ingressos, verificando que possuíam os mesmos códigos de barra, sendo que indagado o réu acabou por confessar a venda de ingressos falsos. Por fim, foi solicitado um representante da “Festa do Peão” para a comprovação da irregularidade nos ingressos.

Por fim, a testemunha Gerson, representante da festa, disse que duas apareceram para confirmar se os ingressos eram ou não verdadeiros, pois um terceiro também queria adquirir. Informou que os ingressos eram falsos. Posteriormente, foi solicitado pela Delegacia para levar alguns ingressos, ante a apreensão de um suspeito. Por fim, para o dia de sábado, o valor do ingresso chegaria a R\$ 1.000,00.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida – Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados – (...) – Sentença mantida – Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de

Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

O réu, ouvido em Juízo, negou a prática do delito, alegando que já trabalhou como "cambista", mas parou pois teve problemas com veracidade de ingresso. Informou que estava em Americana para vender chapéus e canecas, e encontrou uma mulher e dela adquiriu os ingressos, por R\$ 500,00, cada um. Narrou que realmente, na quinta-feira, efetuou a venda de seis ingressos, mas não tentou obter vantagem indevida. Por fim, alega que o flagrante foi orquestrado.

Preliminarmente, sua alegação de que teria adquirido os ingressos de terceira pessoa, e que não tinha conhecimento de que seriam falsos, restou improzada. E, como é sabido, o ônus de provar incumbe a quem faz a alegação.

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a existência de outras demandas, tanto em andamento, quanto sentenciadas, em face do réu pela prática de crimes contra o patrimônio, inclusive estelionato (fls. 81/85), o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

PROVA - Maus antecedentes - Valor: 30(d) - Os antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto condenatório mas constituem importante adinículo para a formação do convencimento. (Apelação nº 1.171.909/6, Julgado em 03/02/2.000, 7ª Câmara, Relator: Corrêa de Moraes, RJTACRIM 47/133)

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina:

"A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

PROVA - Presença de indícios concatenados - Ausência de prova direta que os desautorize - Validade - Entendimento:61 - Sendo a prova indireta mas segura, formada por indícios concatenados, sem contra-indícios ou prova direta que os desautorize, possível é a condenação nela baseada, mormente se a materialidade do delito e inconteste. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 133 RELATOR: - MARREY NETO

PROVA - Furto - Presença de indícios - Valor:182 - Sendo os crimes de furto praticados normalmente sem a presença de testemunhas, os indícios passam a ter valor relevante para a apuração da autoria. RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 324 RELATOR: - MESQUITA DE PAULA

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive não restou comprovado tratar-se de episódio acidental ou dificuldade financeira, mas sim de crime premeditado e reiterado.

Desta forma, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu, mediante artifício, ludibriou, e tentou ludibriar, as vítimas, causando prejuízo e obtendo vantagem econômica.

No mais, há que se analisar que até o momento o réu não ressarcia o prejuízo causado à vítima.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 81/106) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo,

delimitando-a em um ano e dois meses de reclusão e doze dias-multa, para cada delito.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 81/106. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para cada delito.

Relativo aos dois delitos consumados, considerando a existência de duas vítimas, as penas devem ser somadas, razão pela qual fixo a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Relativo ao delito tentado, diminuo a pena da 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido, perfazendo assim um total de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Por fim, ante a ocorrência de concurso material entre todos os delitos as penas devem ser somadas.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu não poderá apelar em liberdade, por ser reincidente. Além disso, o réu encontra-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de

liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu HENI DE OLIVEIRA à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, fixado no piso, como incurso no artigo 171, "caput", por duas vezes, e no art. 171, "caput", c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condeno, ainda, o réu a ressarcir as vítimas J.V.N. e V.M.S., no valor de R\$ 3.900,00, devidamente corrigido desde a data do depósito (16/06/2022 - fls. 197/198).

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.

P. I. C.

Americana, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA